

第 60 問

甲は個人で建築業を営んでいたが、不景気の煽りを受けて、従業員の給与が支払えなくなってしまった。そこで、甲は、融資を受けて立て直そうと考え、知り合いであるAに対して、融資をお願いしたところ、甲の所有する事務所（以下「甲事務所」という。）に1番抵当権を設定することを条件に500万円の融資を受ける契約をした。甲は、甲事務所に対する抵当権設定に必要な書類を全てAに交付すると同時に、500万円の交付を受けたが、その直後に、500万円では足りないと考えた。そこで、甲は、すぐにB銀行へ行き、融資を申し込んだところ、甲事務所に1番抵当権を設定させてもらえれば600万円の融資ができると告げられた。甲は、まだAの抵当権が設定されていないことを奇貨とし、Aとの融資の話を秘して、それが可能である旨をB銀行に告げた上で、抵当権設定に必要な書類を集め、B銀行に交付した。B銀行は、甲を信じたため、これを受け取り、直ちに甲事務所に対する順位が第1位の抵当権設定登記をする、甲に対して600万円を交付した。Aは、これに遅れたため、Aの登記は、2番抵当権となった。

甲の罪責について、論じなさい。

第1 背任罪（247）の成否

1 Aとの間で1番抵当権を設定する契約をした後に、B銀行に1番抵当権を設定させた行為について、Aに対する背任罪の成否が問題となる（**論点** 二重抵当 **司**H24）。

2(1) ここでは、抵当権設定者は他人の事務処理者に当たるかが問題となる。本問では、甲は、既に甲事務所に対する抵当権設定に必要な書類をAに交付しているから、事務処理者ではなくなっているとも思えるが、抵当権者の抵当権取得を妨害しないという消極的義務を負う限度で、他人の事務処理者該当性は否定されないと解されている。判例（最判昭31.12.7【百選Ⅱ70】）も「抵当権設定者はその登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負うものといわなければならない。」と述べており、このような理解に立つものとみられている。

(2) その他の要件としては、「財産上の損害」の有無が問題となる。

背任罪における「財産上の損害」の有無につき、判例（最決昭58.5.24【百選Ⅱ72】）は、「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかった」ことを基準にしており、これによれば、本件のように、得られたはずの1番抵当権を後順位の2番抵当権とすることは、「財産上の損害」に当たることになる。

第2 詐欺罪（246Ⅰ）の成否

1 次に、B銀行との関係において詐欺罪が成立するかが問題となる。

(1) この問題は、基本的には、二重譲渡と横領の問題とパラレルに考えられ、抵当権設定契約の存在を知っていたら融資しなかったであろうと考えられる特別の事情があるときは、例外的に詐欺罪が成立することになる。

(2) 本問では、B銀行は、1番抵当権の設定を受けたことを確認してから600万円を交付しているから、原則として損害がない。そして、本問では、特別の事情を基礎付ける事情は存しないから、詐欺罪は否定されるだろう。

※ B銀行が金融機関であり、担保価値に細心の注意を払うであろうことを強調すると、仮に二重抵当の事実を知れば、B銀行は抵当権設定に応じなかっただろうという評価も可能かもしれない。

2 Aとの関係でも、詐欺罪の成否が問題となる。

ここでも、二重譲渡と横領の問題とパラレルに考えられるところ、三角詐欺構成（最判昭45.3.26【百選Ⅱ56】は、被欺罔者兼処分行為者に財産上の被害者の財産を処分し得る権能又は地位が必要とする。）がとれない以上、詐欺罪は否定される。

答案構成

第1 背任罪（247）の成否

1 背任罪の成否

↓

2 「他人のためにその事務を処理する者」

↓

あてはめ

↓

「自己若しくは第三者の利益を図……る目的」

↓

あてはめ

↓

「その任務に背く行為」

↓

あてはめ

↓

「財産上の損害」（経済的見地から見て実質的に判断する）

↓

あてはめ

↓

3 A に対する背任罪成立

第2 詐欺罪（246 I）の成否

1 B 銀行に対する詐欺罪の成否

↓

「人を欺（く）」行為とは、相手方が財産的処分行為をするための
判断の基礎となるような重要な事実を偽ることをいう

↓

あてはめ

↓

B 銀行に対する詐欺罪不成立

2 A との関係での詐欺罪の成否

↓

三角詐欺の一種

↓

被欺罔者が財産上の被害者の財産を法律上又は事実上処分し得る権
能・地位を有している必要がある

↓

あてはめ

↓

A に対する詐欺罪も不成立

第1 背任罪（247条）の成否

1 Aとの間で1番抵当権を設定する契約をした後に、B銀行に1番抵当権を設定させた行為について、背任罪の成立が考えられる。

2(1) まず、抵当権設定者は、「他人のためにその事務を処理する者」といえるか。

原則として、抵当権設定者は抵当権者に抵当権を得させるという事務を処理する者であるから他人の事務処理者であるとみてよい。

そして、本件では、甲は、甲事務所に対する抵当権設定に必要な書類をAに交付しているが、必要書類を全て手渡している場合も同様に解すべきである。この者も抵当権者の抵当権取得を妨害しないという消極的義務を負っているからである。

したがって、完全に抵当権の設定登記が完了するまで、抵当権設定者は「他人のためにその事務を処理する者」に当たる。

(2) 次に、抵当権設定者である甲には自己や他の抵当権者の利益を図る意図がある以上、「自己若しくは第三者の利益を図……る目的」は認められる。

(3) さらに、上記義務に反し、財産上の損害を惹起し得る行為をしているから、「その任務に背く行為」がある。

(4) また、「財産上の損害」は経済的見地から実質的に判断すべきであるところ、1番抵当権と2番抵当権では担保価値が著しく異なるから、経済的見地から見て実質的に「財産上の損害」が生じたものと言える。

1

したがって、「本人に財産上の損害を加えた」と認められる。

3 甲には故意（38条1項）に欠けるところもないから、Aに対する背任罪が成立する。

第2 詐欺罪（246条1項）の成否

1(1) 上記の二重抵当行為について、まずB銀行との関係において詐欺罪が成立するか、検討する。

「人を欺（く）」行為とは、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいう。

B銀行は、1番抵当権を取得できるから、原則として損害はなく、B銀行の貸付金交付の判断の基礎となる重要な事項の偽りとはいえない。

もっとも、B銀行が、Aとの抵当権設定契約の存在を知っていたら融資しなかったであろうと考えられる特別の事情があるときは、上記重要事項の偽りといえ、例外的に詐欺罪が成立する。

(2) 本件では、そのような特別の事情は認められないから、B銀行に対する詐欺罪は成立しない。

2 次に、Aとの関係で、詐欺罪が成立しないか、検討する。

この点について、甲がB銀行に対し二重に1番抵当権を設定することが、Aとの関係で、被害者をA、被欺罔者をB銀行とする詐欺罪を構成することが考えられる。

しかし、詐欺罪が成立するには、必ずしも被欺罔者と被害者が一致する必要はないものの（三角詐欺）、被欺罔者が財産上の被害者の財産を

2

法律上又は事実上処分し得る権能・地位を有している必要があるところ、本件でB銀行はAの財産を処分し得る権能・地位を有しない。
したがって、Aとの関係でも詐欺罪は成立しない。

以 上

3

4